

1500245-69.2021.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN RIBEIRO DA SILVA

Vistos.

JONATHAN RIBEIRO DA SILVA (RG: 71.898.562, filho de Deusdete Ribeiro da Silva e Sônia Ribeiro da Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 00h58min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500245-69.2021.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 06 de junho de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500245-69.2021.8.26.0593 - Controle 2021/000923

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN RIBEIRO DA SILVA

Vistos.

JONATHAN RIBEIRO DA SILVA (RG: 71.898.562, filho de Deusdete Ribeiro da Silva e Sônia Ribeiro da Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 00h58min, na Rua Bento Biancardi, próximo ao nº 136, Vila Operária da Alimentação II, nesta cidade e comarca de Marília, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de disseminação, 52 (cinquenta e duas) porções contendo 104,7g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, e 172 (cento e setenta e duas) porções contendo 113,86g de

crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia (fls. 96/98), o réu foi citado (fls. 118) e apresentaram resposta à acusação (fls. 125/126).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações ministeriais às fls. 180/187 e alegações defensivas às fls. 192/200.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 19/20 e 22), laudo de constatação (fls. 28/30), laudo químico-toxicológico (fls. 76/80) e pela prova oral colhida.

A testemunha Caio de Sousa Andrade, policial militar, na fase inquisitiva (fls. 5/6), declarou que realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Bento Biancardi quando, na altura do numeral 136, avistaram o acusado acompanhado por uma moça, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, demonstraram certo nervosismo, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Contou que a moça logo foi dispensada e o réu, preso em flagrante, tendo em vista que, em revista pessoal, foram localizadas no interior do bolso de sua bermuda, 5 (cinco) porções de maconha, dois microtubos de cocaína e R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Informou que, auxiliados por um cão farejador, bem próximo ao acusado, em um terreno baldio, lograram êxito em encontrar um saco plástico contendo 105 (cento e cinco) microtubos plásticos com cocaína, 172 (cento e setenta e dois) microtubos plásticos com crack e 47 (quarenta e sete) porções de maconha, todas semelhantes aos entorpecentes encontrados no bolso da bermuda do acusado. Contou que, ao ser questionado pelos policiais, o réu confirmou a propriedade de todo o material localizado e alegou que estava ali para vender o entorpecente. Em juízo, ratificou o que disse na Delegacia e acrescentou que, durante a abordagem, o nervosismo do réu foi percebido porque, quando viu a polícia, tentou abraçar a mulher que estava do seu lado para simular ser sua namorada. Disse que o acusado confirmou que estava no tráfico quando indagado pela testemunha. Contou que a busca realizada pelo cão farejador se deu por volta de três a sete metros do local em que o acusado foi abordado. Não soube informar o nome da moça que acompanhava o réu, disse que ela foi dispensada porque disse que não conhecia Jonathan; esclareceu que tal pessoa não presenciou o procedimento policial. Confirmou que havia várias pessoas na rua, mas só o acusado foi abordado porque seu comportamento se destacou do comportamento dos demais, conforme explicitado, ante a atitude de apenas abraçar a moça que estava ao seu lado após a chegada dos policiais, além do local no qual foi abordado. Afirmou que a rua em que os fatos se deram é de terra e possui residências e, ao final dela, há o início de uma mata, o que causaria ainda mais temor de um ataque contra os policiais durante a abordagem caso resolvessem abordar outras pessoas que estavam no local. Disse que não acompanhou o depoimento do réu na fase inquisitiva e que nunca abordara Jonathan antes dos fatos e não o conhecia. Reforçou que o que fez crer que a droga escondida também seria do réu foi o fato de o cão encontrar a mesma espécie e embalagem de droga achada por ocasião da abordagem, além do fato do próprio acusado afirmar estar atuando no tráfico de drogas. Posteriormente, não reconheceu judicialmente Tauane Jenifer Marques Maciel como a mulher que se encontrava com Jonathan no momento da abordagem.

A testemunha Rogerio Soares Pereira de Melo, Policial Militar, na Delegacia (fls. 7), confirmou os fatos narrados pela testemunha Caio de Sousa Andrade. Em juízo, acrescentou que, durante o patrulhamento, avistaram o acusado conversando com uma mulher a certa distância e, no momento em que ele viu os policiais, demonstrou certo nervosismo, tentou segurar a moça e ela se esquivou. Disse que as drogas escondidas foram encontradas de quatro a sete metros do local da abordagem. Afirmou que o acusado confessou, informalmente, que comercializava entorpecentes naquela oportunidade. Contou que abordou o réu e, quanto à mulher, apenas pediu para que ela mesma apalpasse o próprio corpo para verificar se havia algo escondido e, então, ela foi dispensada. Disse que optaram por sair rapidamente do local pelo fato de ser uma região em que, caso permanecessem por muito tempo, poderia haver

grande aglomeração de pessoas e traria risco aos policiais. Confirmou que a droga ocultada era muito semelhante à encontrada em posse do acusado. Negou conhecer Jonathan. Disse que não conhecia a mulher que se encontrava com o réu no momento da abordagem e que ela disse, na oportunidade, que não conhecia o acusado. Afirmou que não teve como conduzir testemunhas do local e que há residências próximas de onde a abordagem aconteceu. Posteriormente, por não conseguir se recordar, não reconheceu judicialmente Tauane Jenifer Marques Maciel como a mulher que se encontrava com Jonathan no momento da abordagem.

Ouvida apenas em juízo, a informante Tauane Jenifer Marques Maciel (menor de idade e que teve como responsável o próprio advogado de defesa) declarou que é namorada do réu. Afirmou que Jonathan foi buscar drogas para uso próprio e que estava junto dele no momento da abordagem. Disse que foi dispensada pelos policiais por ser menor de idade (17 anos). Nega que tenha dito que não conhecia o acusado quando indagada pelos policiais no local dos fatos. Contou que viu os policiais vindo, abordando o réu e encontrando cinco cigarros de maconha e dois microtubos de cocaína com ele. Narrou que os policiais pediram para que o acusado apontasse de qual traficante adquiriu a droga, mas o réu não soube informar. Disse que a droga foi comprada em um terreno baldio e que sempre o acompanhava até o local. Afirmou que namora o réu desde dezembro e que o acusado havia parado de usar entorpecentes, mas teve uma recaída. Contou que o réu já foi preso quando menor e que foi comprar entorpecentes após receber de Pedro o pagamento advindo do seu trabalho como pintor – R\$300,00 (trezentos reais) por semana. Não soube informar de quem o réu comprou a droga e disse que o traficante correu ao avistar a polícia. Confirmou ser namorada do acusado e que estava com ele na hora dos fatos, bem como que queria acompanhá-lo até à delegacia, mas foi dispensada pelos policiais. Afirmou que, antes dos fatos, morava com o próprio acusado e, depois, passou a morar com o irmão dele. Ao ser questionada sobre o motivo do advogado de defesa ter indicado o endereço de sua tia para encontrá-la, afirmou que lá morou por um tempo. Por fim, não soube informar o endereço da casa do irmão do réu.

A testemunha arrolada pela defesa, Pedro Cesar Aguiar, ouvido apenas em juízo, disse que não é parente ou amigo íntimo de Jonathan. Declarou que soube dos fatos depois de acontecerem. Informou que o acusado trabalhava com ele como ajudante de pintor e fazia o pagamento semanal (todo sábado) de R\$300,00 (trezentos reais) à mãe dele, pelo fato do acusado não saber ler, escrever ou lidar com dinheiro. Contou que, depois que o réu passou a ter uma união estável com uma mulher, começou a fazer o pagamento diretamente para eles. Explicou que a jornada de trabalho do acusado era das 7h às 17h e, na época dos fatos, estavam trabalhando próximo ao MAC. Não se lembrou do dia da semana em que o réu foi preso e disse que trabalharam juntos por dois anos. Por fim, afirmou que Tauane Maciel era a companheira de Jonathan.

O acusado, por sua vez, em solo policial (fls. 8), reservou-se ao direito de permanecer calado. Em juízo, declarou que recebeu seu pagamento e foi junto de sua mulher comprar drogas (duas porções de “pó” e cinco “paranga”). Contou que, quando se virou, viu o sujeito que lhe vendeu a droga correndo, mas que decidiu permanecer no local. Narrou que foi abordado pelo policial e que o cachorro farejou drogas escondidas. Disse que o policial lhe disse: “já que não sabe de quem é a droga, então ela é sua”. Não soube informar quem lhe vendeu a droga, apenas que era um homem alto, branco, com tatuagem e cerca de vinte anos de idade. Disse que, depois que voltou a usar entorpecente, sempre os adquiria naquele local. Não se recorda de quando voltou a usar drogas. Contou que usava cerca de seis “pó” e cinco “parangas” por dia. Informou que pagava R\$10,00 (dez reais) pelo “pó” e R\$5,00 (cinco reais) pela “paranga”. Disse que, na época, morava com sua mulher na casa de sua finada avó e somente ele trabalhava (como pintor, ganhando trezentos reais por semana). Afirmou que não usa drogas na penitenciária nem passou por tratamento para drogadição, bem como que nunca foi internado e não se recorda de já ter respondido a processos. Contou que não frequentou a escola e não sabe ler, escrever, realizar cálculos matemáticos nem reconhece valores monetários.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem, neste caso concreto, que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas. Neste sentido: “Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) “É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)” (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda, por analogia: “Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes

públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam, conforme relatado por ambos.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou condutas descritas nos artigos 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, ter em depósito e trazer consigo substância entorpecente sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, em patrulhamento, os policiais militares perceberam comportamento suspeito do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas, eis que, ao notar a presença da viatura, tentou se aproximar de uma moça que estava próxima a ele, mas ela se esquivou, dizendo, depois, aos policiais, que não o conhecia, motivo pelo qual foi dispensada. Assim, ao abordarem o acusado, localizaram no interior do bolso de sua bermuda 5 (cinco) porções de erva esverdeada e 2 (dois) microtubos contendo pó branco semelhante a cocaína, além de uma nota de R\$20,00. Com auxílio do cão farejador, bem próximo ao acusado, em um terreno baldio, sob alguns entulhos, foram localizados 105 (cento e cinco) microtubos plásticos com cocaína, 47 (quarenta e sete) porções de maconha e 172 (cento e setenta e dois) microtubos contendo crack. O laudo de constatação (fls. 28/30) comprovou a presença de tetrahydrocannabinol em invólucros plásticos, além de cocaína em microtubos plásticos. No mesmo sentido, o laudo químico-toxicológico (fls. 76/80).

Ainda, há que se analisar mais profundamente os depoimentos prestados em juízo. O depoimento de Pedro nada traz a respeito dos fatos; apenas deu conta que Tauane é companheira do réu. Quanto às declarações de Tauane, há mais para examinar.

Primeiramente, necessário salientar a postura da depoente, sempre olhando para seu advogado antes de responder às questões formuladas pelo juízo, como se buscasse informações ou confirmações de cada frase dita. Em segundo lugar, foi ouvida na condição de informante do juízo por se declarar namorada do réu e, portanto, não tinha o dever legal de falar a verdade, o que enfraquece, evidentemente, a força probante daquilo que disse, eis que é evidente que, pela relação próxima, quer favorecer o namorado. Por fim, no desfecho de seu depoimento, Tauane não soube informar o endereço em que alega morar e abaixou a cabeça, buscou seu advogado com o olhar e ofereceu resposta sem qualquer verossimilhança. Na medida em que o depoimento é pessoal e faz parte da busca pela verdade possível, sua conduta faz com que se questione a credibilidade de suas palavras.

Mas não é só: não se pode esquecer que a suposta “testemunha ocular”, Taune, não teve a identidade confirmada, eis que não reconhecida, em juízo, pelos policiais que abordaram o réu como a moça que ele tentou abraçar naquela oportunidade e que dele se esquivou, chamando a atenção dos PMs e levando, pois, à ação dos guardas, mas que logo foi dispensada, eis que negou conhecer Jonathan.

Já com relação ao interrogatório do acusado, é incoerente com o conjunto probatório. Isto é, o réu acusa os policiais de o terem prendido porque ele não quis identificar quem lhe vendeu o entorpecente que tinha consigo (“já que não sabe de quem é a droga, então ela é sua” - teriam lhe dito os PMs). Mas não trouxe nenhuma prova segura de suas alegações, ônus que lhe cabia, conforme a melhor doutrina e jurisprudência. Vejamos: “A negativa do réu não lhe favorece. Não fez prova do que alega (...) Destaca-se, quanto ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. Neste caso, existindo alegação da defesa que se

contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado. (...) GUSTAVO BADARÓ reforça tal entendimento ao declarar que o ônus de prova é uma “posição jurídica na qual o ordenamento jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito onerado obtenha o resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não realização da conduta implica na exclusão de tal benefício, sem, contudo, configurar ato ilícito”. Este é o caso dos autos, onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados. Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se. (...) não pode alegar a defesa que, por seu descaso, o fato por ela alegado e não provado, deve ser aceito em nome da “busca da verdade real” ou do “princípio da presunção de inocência”. (Apelação Criminal n. 1500373-26.2018.8.26.0551, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, j. 27/7/2020)

Nem mesmo sua namorada, que estava com ele, segundo sua versão, pôde confirmar o que o acusado alegou, já que, em se considerando que era mesmo a pessoa que estava ao lado do réu (o que não se pode afirmar, repese-se), não presenciou a ação policial, eis que dispensada incontinenti, segundo o depoimento dos policiais e da própria testemunha em juízo.

A respeito da credibilidade das palavras dos policiais, não há mais o que acrescentar. Ainda que tenham procedido ao flagrante (qualquer de suas espécies legais), tal circunstância não faz deles suspeitos, conforme decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. (...) 2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra dos entorpecentes e a transação não ter se concluído em razão da prisão em flagrante dos acusados, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de os sentenciados, tanto o corréu quanto o agravante, terem guardado em depósito e trazido consigo as drogas apreendidas, condutas que, a toda evidência não foram instigadas ou induzidas pelos agentes, o que afasta a mácula suscitada na impetração. (AgRg no AREsp n. 1.579.303/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Importante consignar que ambos os policiais afirmaram ter encontrado a droga ocultada a, no máximo, sete metros de distância do local de abordagem do réu. Essencial, também, enfatizar que, em juízo, os policiais disseram que tanto a droga quanto as embalagens encontradas com o acusado eram semelhantes às embalagens e à droga achadas pelo cão farejador.

Por último, vale consignar que ele afirmou fazer uso de drogas diariamente e, segundo suas próprias palavras, é possível apreender que gastaria cerca de R\$75,00 (setenta e cinco reais) por dia somente com entorpecentes, enquanto recebia cerca de R\$300,00 (trezentos reais) por semana por sua atividade como pintor. Ora, em quatro dias gastaria todo o pagamento com drogas, não se olvidando que ele afirmou que era o único responsável por sustentar a casa. Há, também, uma inconsistência quanto a alegação de vício em drogas: ao que consta, não apresentou quaisquer sintomas de abstinência ou recebeu tratamento médico durante seu período de recolhimento na penitenciária.

No mais, sobre o elemento subjetivo do tipo do artigo 33 da LD, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro “Lei de drogas comentada artigo por artigo” (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): “O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'”.

Ainda, a solução legal para se concluir pela condição de traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (172 porções de cocaína e 52 porções de tetrahidrocannabinidiol - 104,7g de maconha e 113,86g de crack), seu alto poder vulnerante, bem como as circunstâncias da prisão do réu, que teve envolvimento com a traficância enquanto adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 114), não deixam dúvida de que se trata, ele, de traficante.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o acusado, ao que consta, se dedica à atividade criminosa, ou seja, o histórico de envolvimento do acusado com o tráfico (foi apreendido quando menor), bem como a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício. Ainda, destaco que, conforme decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (cuja ementa se encontra colacionada a seguir), o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO DEFINITIVAS. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). 3. Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. 4. Hipótese em que o redutor não foi aplicado com base no fato de o paciente possuir diversos registros anteriores, como atos infracionais praticados quando menor, inclusive por tráfico de drogas, além de recente condenação criminal pela prática do mesmo delito, a denotar dedicação a atividades criminosas. 5. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021) Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e a materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida, além do seu alto poder vulnerante, autoriza a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta. Assim, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuantes da menoridade relativa, motivo pelo qual torno a pena no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual resta como definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

A pena pecuniária é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor

unitário de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Ainda, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, ante os critérios legais expostos nos artigos 33 e seguintes e 59 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, ante a quantidade, além do fato de se tratar de delito equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios no caso concreto, até pelas circunstâncias levadas em consideração quando do aumento da pena na primeira fase de fixação.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do Estabelecimento em que se encontra o preso, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar JONATHAN RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por ser incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto das condutas por ele praticadas, já mencionada na decisão que decretou a prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos crimes e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontrar recolhido.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 63 da Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do valor de R\$20,00, apreendidos às fls. 12/13, oficiando-se à FUNAD.

Oportunamente, expeça o necessário para o cumprimento das penas impostas e desta sentença, oficiando, inclusive, ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, s eo caso.

P.I.C.

Marília, 5 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA